

1512333-58.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316365/2021 - DEL.POL.ARARAS, 21506557 - DEL.POL.ARARAS, 4564/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2316365 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FABIANO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512333-58.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512333-58.2021.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316365/2021 - DEL.POL.ARARAS, 21506557 - DEL.POL.ARARAS, 4564/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2316365 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FABIANO MALAMAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado LUIZ FABIANO MALAMAN já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Tercília Alves Cavalheiro Franzini, altura do número 70, Vila São Jorge, nesta cidade de Araras, o réu trazia consigo, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dentro de uma bolsa, que dispensou com aproximação de Guardas Municipais, 18 (dezoito) pedras de crack, com peso líquido de 1,75 gramas, e 23 (vinte e três) eppendorff com cocaína, com peso líquido de 4,7 gramas, e no bolso de sua cala a quantia em dinheiro de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

O réu foi notificado (fls. 140) e apresentou defesa preliminar (fls. 128/133).

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fls. 141/142) e o acusado foi citado (fls. 202).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 203/204), sendo o réu interrogado ao final (fls. 205).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 211/217) e (fls. 221/228 e 229/237). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, com juntada de declaração de internação do acusado para tratamento de dependência química (fls.238), com os protestos ministerial (fls.242).

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Preliminarmente, indefiro o pedido de instauração de incidente.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a determinar que se faça o exame de dependência toxicológica, pois a ele cabe a faculdade de determinar ou não a sua realização, caso haja a possibilidade de inimizabilidade do acusado, ainda que de forma reduzida.

É somente imprescindível a instauração quando houver dúvida acerca da insanidade ou da dependência toxicológica.

Confira-se, a esse respeito, julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“O Código de Processo Penal obriga ao exame quando houver dúvida sobre a insanidade e não quando a defesa o requeira. Assim, o Magistrado somente deferirá o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental quando presentes indícios de perturbação ou algum motivo, pelo menos, para duvidar da normalidade psíquica, que é regra geral” (TACRIM-SP, JUTACRIM 84/206).

Lembre-se que mero uso de drogas, ainda que prolongado, não implica necessariamente em dependência química.

No mais, conforme entendimento majoritário no STJ (HC 258463/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma) a mera suspeita ou afirmação de que o acusado seja usuário de substâncias ilícitas não justifica a realização de exame em análise.

Vejamos:

“A simples alegação de ser o réu viciado em substâncias entorpecentes não obriga o magistrado a realizar o exame de dependência toxicológica, porquanto cabe ao juiz, no caso concreto, avaliar a conveniência e a oportunidade de sua realização” (RHC 14.789/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª. Turma, julgado em 07.10.2003, DJ 10.11.2003 p. 198)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes Preliminar - Nulidade decorrente do indeferimento de realização de exame toxicológico Inocorrência. Ausência de indícios de que a corré Eliane era inimputável pela dependência química. Prescindibilidade da perícia”. (TJSP, 4ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação

nº 0001016-16.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Camilo Léllis, São Paulo, 31 de janeiro de 2017).

Ademais, como lecionava Borges da Rosa: “a efetuação de exames desnecessários ao esclarecimento da verdade atentaria contra os requisitos superiores do processo: celeridade, simplicidade e moralidade” (TJSP, trecho de acórdão da apelação criminal nº 0003100-19.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Lauro Mens de Mello, citando decisão extraído do livro *Jurisprudência e Doutrina Criminais*, Mohamed Amaro, vol. II, 1979, p. 895).

O documento de fls.237 não é apto a demonstrar o vício atual, eis que datado de 2010.

No mérito, improcede a pretensão punitiva estatal. Vejamos:

Interrogado em juízo, o réu narrou que estava no local usando drogas pois é viciado e havia brigado com sua esposa. Disse que não correu e acredita que ficou detido por passagem anterior. Negou vender drogas no local. Afirmou que é usuário de crack e cocaína. Por fim, disse que no local havia outras pessoas fazendo uso de droga e que as porções eram de outras pessoas que fugiram (fls. 205).

De outro lado, os guardas municipais, afirmaram que estavam em patrulhamento em ponto de tráfico quando avistaram aglomeração de usuários que se dispersaram ao notar a chegada da viatura. Disseram ainda que viram o réu jogando um invólucro em terreno ao baldio, dentro do qual estavam 18 porções de crack e 23 de cocaína. Com o denunciado, apreenderam 60 reais (fls.203/204).

São as provas dos autos.

A absolvição é de rigor.

Isso porque, ilegal a ação dos guardas municipais.

Nesse sentido, não se nega a validade de prisões em flagrante realizadas por Guardas Municipais, tal qual é permitido a qualquer pessoa do povo, com base no art. 301, do CPP.

Entretanto, não é esse o caso dos autos.

De fato, “in casu”, os guardas, ainda que de boa-fé, extrapolaram suas funções, exercendo verdadeira atividade investigativa e ostensiva, de incumbência respectiva da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Nesse sentido, é dos que estavam em patrulhamento ostensivo em ponto de tráfico e avistaram aglomeração de adictos, notando que o réu teria se desfeito de algo, passando, então, a investigar o que teria sido por ele dispensado. Resta, assim, evidente que realizaram tarefas para as quais não possuem atribuição, violando o princípio da estrita legalidade aplicável aos agentes estatais.

De fato, com essa conduta, os guardas civis municipais infringiram o disposto no artigo 144, §8º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O art. 144, da CF/1988 é claro ao atribuir o policiamento ostensivo exclusivamente à Polícia Militar e a função investigativa compete à Polícia Civil, facultando aos Municípios a criação de Guardas Civis para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Como dito, não se desconhece que qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como acima já disposto e como disciplina o Código

de Processo Penal, em seu artigo 301.

Entretanto, no caso concreto, não havia prévia situação de flagrante delito que permitisse a atuação da Guarda Civil Municipal ou de qualquer pessoa do povo.

Assim, patente a ilegalidade da ação dos guardas civis municipais.

Nem mesmo a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das Guardas Municipais, autoriza as guardas exerçam atividades típicas da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Nesse sentido, em ação direta de inconstitucionalidade de nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), o E. Tribunal Paulista deliberou que:

"(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas."

Em Recurso Extraordinário (nº 608.588/SP), ainda pendente de julgamento, contra mencionado "decisum", o ilustre Procurador-Geral da República, asseverou que:

"Estão fora das atribuições constitucionais das guardas municipais as atividades que extrapolem a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, como as de policiamento ostensivo fora desse contexto, as de polícia judiciária e a apuração de infrações penais".

Desta feita, atento ao princípio da legalidade estrita, aplicável aos agentes estatais, bem como ao disposto no §8º, do art. 144, da CF/1988, concluo pela ilegalidade na atuação dos guardas municipais no caso presente.

Sobre o tema, importante transcrever recentes julgados do E. STJ:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal" (grifamos STJ, RHC nº 142.588/PR, 6ª Turma, Rel. o Min. Olindo Menezes, j. em 25.05.2021).

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em

postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP" (grifamos; STJ, HC nº 561.329/SP, 6ª Turma, Rel. o Min. Nefi Cordeiro, j. em 16.06.2020, DJe 29.06.2020).

No mesmo diapasão são as decisões do Tribunal Paulista:

"HABEAS CORPUS. Investigação e prisão em flagrante em função típica de policiamento ostensivo, iniciada por ação típica de Polícia Judiciária, por Guardas Civis Municipais. Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar e/ou à Polícia Civil. Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal. Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida. Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência. Ordem CONCEDIDA". (grifamos; TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2277974-66.2021.8.26.0000)

"Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar. Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância. Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido". (grifamos; TJSP, APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502753-49.2019.8.26.0272)

"Crimes de estelionato e corrupção de menores - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal - Precedentes desta 12ª Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça - Abordagem realizada em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais e em verdadeira atividade investigativa, funções típicas reservadas constitucionalmente à Polícia Militar e à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Prova ilícita Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO". (grifamos; TJSP, Apelação Criminal nº 0002166-05.2017.8.26.0068)

A nulidade do flagrante enseja, por consequência, a invalidade das provas colhidas e trazidas aos autos, impondo-se a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu LUIZ FABIANO MALAMAN já qualificado nos autos, nos moldes da fundamentação, por falta de provas, com base no art. 396, VII, do CPP.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a devolução do numerário apreendido. Autorizo a destruição das drogas. Oficie-se.

Oportunamente, arquivam-se. P.R.I.

Araras, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA